

学生A及びBは、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの()内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの()内には、それぞれ異なるものが入る。

【会話】

学生A. 未遂犯の刑について、刑法は、どのように定めていますか。

学生B. 刑法第43条は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を(①)。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減輕し、又は(②)。」と定めています。

学生A. 未遂を罰する場合、明文で定める必要があるかについて、刑法は、どのように定めていますか。

学生B. 刑法第44条は「未遂を罰する場合は、各本条で定める。」と定めています。例えば、背任罪の未遂は(③)が、横領罪の未遂は(④)。

学生A. 侵入窃盗について、窃盗の実行の着手をどのように判断しますか。

学生B. (⑤)の場合、侵入しただけでは実行の着手は認められず、財物の物色行為に至れば実行の着手が認められると考えます。

学生A. (⑤)の場合、財物の物色のためにたんすに近寄ったとしても、物色行為に至らなければ実行の着手は認められないのですか。

学生B. 判例によれば、財物の物色行為に至らなければ(⑥)。

学生A. (⑦)の場合、(⑧)に取り掛かった時点で、実行の着手が認められるとした裁判例がありますが、これについてはどう考えますか。

学生B. 賛成です。通常、(⑦)の内部は財物を保管するためにだけ用いられており、(⑧)に取り掛かった時点で内部の財物が窃取される現実的危険性が生じていると考えます。

【語句群】

a. 減輕する b. 減輕することができる

c. 免除する d. 免除することができる

e. 処罰されます f. 処罰されません

g. 通常の住居 h. 土蔵

i. 実行の着手が認められないということではありません

j. 実行の着手は認められません k. 犯行計画の策定 l. 侵入行為

1. ①a ③f ⑥j ⑧k

2. ①b ④e ⑤h ⑦g

3. ②c ⑤g ⑦h ⑧k

4. ②d ④f ⑥i ⑦h

5. ③e ⑤g ⑥i ⑧l

Na134	未遂犯	正答率
R7-13	5	66%

()には順に、「①= b、②= c、③= e、④= f、⑤= g、⑥= i、⑦= h、⑧= l」と入り、したがって、正解は肢5となる。

①、②について

43条は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減輕することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減輕し、又は免除する。」と規定している。よって、①には「b. 減輕することができる」が入り、②には「c. 免除する」が入る。

③、④について

背任罪(247条)の規定がある章には、未遂規定(250条)がある。一方で、横領罪(252条)の規定がある章には、未遂規定がない。よって、③には「e. 処罰されます」が入り、④には「f. 処罰されません」が入る。

⑤、⑥について

大判昭9.10.19は、窃盗目的で通常の住居に侵入し、金貨物色のためタンスに近寄ったが、財物を得ないうちに家人に誰何された事案において、通常の住居に侵入し金品物色のためにタンスに近寄った行為は、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接なる行為として、窃盗罪の実行の着手を認められるとした。よって、⑤には「g. 通常の住居」が入り、⑥には「i. 実行の着手が認められないということではありません」が入る。

⑦、⑧について

名古屋高判昭25.11.14は、窃盗目的で土蔵に侵入しようとし、土蔵の壁の一部を破壊したが家人に発見された事案において、土蔵に侵入しようとして土蔵の壁の一部を破壊した時点、つまり侵入行為をした時点で窃盗罪の実行の着手が認められるとした。なぜこの裁判例では、上記大判昭9.10.19と異なり侵入行為という早い時点で窃盗罪の実行の着手を認めているかというと、土蔵には通常その内部に窃取すべき財物のみがあり、かつ人が住んでないので、侵入して内部で物色を始めなくても、侵入しようとした時点で内部の財物が窃取される現実的危険性が認められるからであるという説明がされている。よって、⑦には「h. 土蔵」が入り、⑧には「l. 侵入行為」が入る。